

0005422-23.2014.8.26.0597

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... denúncia, os acusados praticavam o tráfico de drogas no local. Para tanto, mantinham no interior da residência, escondidos, próximo ao muro de fornecimento das drogas, os entorpecentes apreendidos a fls. 27/28, oportunidade em que policiais militares em diligências efetuaram a abordagem. A fim de praticarem o tráfico, OSVALDINO e ALEXANDRE dividiram funções, sendo ALEXANDRE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005422-23.2014.8.26.0597 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005422-23.2014.8.26.0597

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 269/2014 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Sertãozinho, 124/2014 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Sertãozinho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS e ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 01 de agosto de 2014, às 03h30min, na Rua Luís Antônio Bombonati Talan nº 611, Jardim Helena, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins de venda, 147,24 g de maconha e 156,57 g de cocaína, conforme laudo pericial de fls. 58.

Segundo a denúncia, os acusados praticavam o tráfico de drogas no local. Para tanto, mantinham no interior da residência, escondidos, próximo ao muro de fornecimento das drogas, os entorpecentes apreendidos a fls. 27/28, oportunidade em que policiais militares em diligências efetuaram a abordagem. A fim de praticarem o tráfico, OSVALDINO e ALEXANDRE dividiram funções, sendo ALEXANDRE responsável pela comercialização das substâncias ilícitas, enquanto OSVALDINO coordenava os atos de mercancia. A forma como estavam acondicionadas a cocaína e a maconha, bem como a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, incompatível com a destinação do próprio consumo, evidencia o propósito da mercancia.

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2015 (fls. 209). Os réus foram devidamente citados (Alexandre - fls. 497, Osvaldino - fls. 508) e apresentaram resposta à acusação (Alexandre - fls. 176/177, Osvaldino - fls. 200/208).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e outras duas testemunhas arroladas pela Defesa, sendo os réus interrogados ao final. Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 651/659).

A Defesa do réu Alexandre requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a fixação de penas mínimas, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade (v. fls. 674/677).

A Defesa do réu Osvaldino, preliminarmente, sustentou a ocorrência de nulidade na prova colhida, posto que sua residência foi arrombada e invadida pelos policiais, contrariando a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, além de ilicitude da prova baseada em denúncia anônima. Também sustentou inexistir prova suficiente para a condenação e também que não ficou caracterizado o delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente pugnou pela fixação de penas mínimas, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como a fixação de regime aberto (fls. 703/721).

É o relatório.

DECIDO

Ficam afastadas as preliminares arguidas pela Defesa do réu Osvaldino.

Não vislumbro qualquer dos vícios alegados em relação à ausência de mandado de busca e apreensão no imóvel local dos fatos. Embora tenha alegado a Defesa que a prova obtida deve ser declarada nula, ante a ausência de justificativa suficiente para a entrada dos policiais militares no imóvel, a tese não prospera, porquanto foram vários os fatores que caracterizavam a justa causa para a ação policial.

Com efeito, é certo que foi avistado um indivíduo comprando entorpecentes no referido imóvel, momento em que, ao observar a chegada da viatura policial, evadiu-se do local. Ademais, foi possível a visualização de drogas no interior da residência, também havendo a comprovação de que o local se tratava de conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, o qual era conhecido como "biqueira da janelinha".

Ademais, foi imputado aos réus o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06), na modalidade "ter em depósito", sendo certo que se trata de crime permanente, cujo estado de flagrância se protraí no tempo.

Em relação à ilicitude da prova colhida com base inicial em notícia anônima de crime, não há vício a ser reconhecido. Os agentes de segurança já haviam empreendido diligências anteriores no local dos fatos, com êxito na localização e apreensão de drogas, circunstância sobressalente que justifica a abordagem feita no imóvel. Desta forma, não foi a denúncia anônima o único elemento de convicção dos policiais para realização da diligência tratada nos autos, mas também sedimentada em providências anteriores afetas ao poder ofensivo estatal inerentes às suas funções.

Neste sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DO AVISO DE MIRANDA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA; HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 742.003/SP, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Quanto à alegação da Defesa de que as provas foram obtidas por meio ilícito, esta também não prospera. Não restou comprovado e não há motivos para suspeitar de que o réu Alexandre tenha sido torturado com equipamentos de eletrochoque na região da barriga, o que o teria feito confessar o envolvimento do corréu Osvaldino. De outro modo, está acostado nos autos relatório médico dando conta de que Alexandre, na data dos fatos, passou por atendimento, foi examinado e não apresentava nenhuma lesão aparente.

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06 - Alexandre), pelo boletim de ocorrência (fls. 24/25), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), pelo auto de constatação preliminar (fls. 32), pelas imagens fotográficas (fls. 29/30), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 58), conclusivo por se tratar de cocaína e maconha, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e repousa sobre os acusados.

Os policiais militares Ronaldo e Gustavo, ouvidos em sede policial, declararam que, na data dos fatos, por volta das 03h30min, receberam notícia anônima informando que na residência situada na Rua Luís Antônio Bombonati Talan nº 611, Jardim Helena, Sertãozinho, de propriedade do réu OSVALDINO, estariam praticando o tráfico de drogas. Ato contínuo, ao se deslocaram para lá, cerca de 2 quarteirões do local, observaram um veículo Toyota Hilux, de cor branca, parado defronte ao local, bem como um indivíduo na calçada, próximo a uma boqueta ali existente, o qual rapidamente se evadiu, não sendo possível sua abordagem, nem a anotação da placa do veículo. Diante de tais fatos, resolveram adentrar o local, dotado de portão e paredes reforçadas, e, por meio de uma fresta existente no muro lateral, entre o telhado e o muro, providenciaram sua abertura para acesso ao interior da residência. Já no interior do imóvel, abordaram o réu ALEXANDRE, não sendo encontrado com ele nada de ilícito. Contudo, após diligências, próximo à boqueta, foram encontradas 80 (oitenta) porções de maconha e 87 (oitenta e sete) cápsulas de cocaína, todas embaladas e prontas para a comercialização, bem como a quantia de R\$ 1.038,00 (mil e trinta e oito reais) em notas trocadas e em pequeno valor. Ademais, passaram a indagá-lo sobre a existência de mais drogas no local, momento em que ALEXANDRE informou que havia dispensado mais drogas no ralo do tanque e soltado água para que elas descessem. Ao utilizarem de ferramentas, conseguiram quebrar o piso e acessar o canal de esgoto do local mencionado, localizando outras 370 (trezentas e setenta) cápsulas de cocaína, prontas para consumo, bem como a quantia de 60 (sessenta) reais em dinheiro. Ainda, no local, foi visualizada uma televisão marca AOC, ligada a cabos de vídeo de vigilância, os quais monitoravam o local por câmeras, tendo sido apreendida. Por fim, indagaram novamente ALEXANDRE a respeito dos entorpecentes, momento em que ele afirmou que “apenas” trabalhava no local, a cerca de 1 (um) mês, para OSVALDINO, em troca de R\$600,00 (seiscentos reais) por noite de “serviço”. Este também disse que não conhecia o corréu pessoalmente, mas sabia que ele era recém egresso do sistema prisional por tráfico de drogas (fls. 07/08 e 09/10).

Em Juízo, o policial militar Ronaldo declarou que, em datas anteriores aos fatos, já havia diligenciado o local da denúncia e tomado conhecimento de que ali funcionava uma “biqueira”. Após a denúncia, deslocaram-se para lá e se depararam com um indivíduo saindo do local, contudo, não conseguiram abordá-lo. Ato contínuo, adentraram a residência e localizaram entorpecente que aparentava ser maconha, bem como cocaína em pinos e dinheiro em espécie. Parte das drogas estava em um balcão na residência, e outra parte estava dentro de um encanamento. Dentro do local, indagaram ALEXANDRE, o qual informou até mesmo o turno de horas que ficava por lá, já que trabalhava para OSVALDINO. Disse que já conhecia OSVALDINO anteriormente, porque já o abordou em ocorrências anteriores, mas não encontrou com ele nada de ilícito. Ademais, disse não conhecer ALEXANDRE e afirmou que o nome de OSVALDINO não constava na denúncia anônima recebida (v. mídia)

Em Juízo, o policial militar Gustavo declarou que receberam denúncia de que no local dos fatos ocorria tráfico de drogas. Esclareceu que em datas anteriores já haviam se deslocado para lá e apreenderam certa quantidade de entorpecentes, sendo que o local era conhecido como “biqueira da janelinha”. Na data dos fatos, depararam-se com um indivíduo fazendo a compra de entorpecentes, momento em que, ao avistar a viatura, ele empreendeu fuga. Pelo muro da residência, era possível visualizar que havia drogas no local, motivo pelo qual lá adentraram. Em sequência, já dentro do imóvel, abordaram ALEXANDRE e encontraram certa quantidade de maconha e cocaína próxima à janela, bem como uma quantia em dinheiro. Ao questioná-lo se havia mais entorpecentes no local, ele disse que havia dispensado alguns entorpecentes pelo cano de água, momento em que, utilizando de ferramentas, conseguiram quebrar o local informado e encontraram mais drogas. Ademais, disse que no local havia uma televisão e sistema de monitoramento. ALEXANDRE ainda esclareceu que trabalhava no local para OSVALDINO, sendo que recebia R\$600,00 (seiscentos reais) por noite de serviço. Disse que já conhecia OSVALDINO de outras diligências, mas não conhecia ALEXANDRE (v. mídia).

A testemunha Nivaldo Santos Torres, arrolada pela Defesa, declarou que conhece OSVALDINO há quatro anos. Disse que é comerciante, tem um mercado e um depósito de bebidas, e sabe que o réu trabalhava na área de construção civil. Informou que não sabe o endereço de OSVALDINO, mas tem conhecimento de que ele mora em Ribeirão Preto. Por fim, disse não conhecer ALEXANDRE (v. mídia).

A testemunha Alex Francisco do Rosário, arrolada pela Defesa, declarou que conhece OSVALDINO há quatro anos. Disse que ele mora em Ribeirão Preto e sabe que ele trabalha com construção, sendo que o conheceu através da irmã dele, Cida, porque ela mora perto de sua mãe. Por fim, afirmou que não conhece ALEXANDRE (v. mídia). O réu Alexandre, quando interrogado na fase policial, negou a prática delitiva. Declarou que morava no local dos fatos e estava dormindo, momento em que percebeu que alguém quebrava a área entre o telhado e o muro de sua residência, tendo observado que se tratava de policiais militares. Estes entraram no local e o revistaram, sem nada encontrar. Foi agredido enquanto os policiais perguntavam onde estava a droga. Disse que já tinha se livrado dela e, então, eles começaram a cavar para chegar até o sistema de esgoto. Novamente, nada de ilícito foi encontrado. Após, os policiais quebraram a porta de sua geladeira e picharam suas paredes. Ato contínuo, pegaram um pacote de drogas e exibiram para ele, dizendo que aquilo lhe pertencia. Negou a propriedade de entorpecentes, bem como afirmou não conhecer OSVALDINO (fls. 12/13).

Em juízo, o réu Alexandre declarou que, na data dos fatos, por volta de 3h30min, estava dormindo quando ouviu um barulho e decidiu averiguar. Deparou-se com policiais militares em seu telhado, sendo que eles quebraram a laje para poder entrar no local. Já dentro do imóvel, os policiais diziam para ele ficar quieto. Após, perguntaram se havia drogas no local, tendo ele negado. Como os policiais não encontraram nada de ilícito, começaram a dar choques nele. Após, acordou na cozinha com um policial jogando água em seu rosto. Em sequência, um dos policiais, RONALDO, foi até a viatura e pegou uma sacola com entorpecentes, entregando para ele e tendo dito que era sua. Em seguida, os policiais acharam R\$1.100,00 (mil e cem reais) em dinheiro que lhe pertencia, proveniente de serviço como mecânico que havia recebido no mês anterior aos fatos. Declarou que não conhecia OSVALDINO, e que somente tomou conhecimento dele na presente data. Afirmou que fazia uso de maconha. Disse que conhecia os policiais militares de vista. Esclareceu que fazia 15 dias que havia alugado a casa de uma pessoa chamada “Toninho”, mas não havia firmado contrato escrito. Disse que não havia câmeras na residência, mas tão somente uma câmera do vizinho (um bar), que era de enfeite. Havia poucos móveis no local, tais como uma cama, frigobar, micro-ondas e fogão. Afirmou que os policiais quebraram paredes da residência, bem como a pia e o vaso, sendo que está em dívida com “Toninho” por conta disso (mais de R\$3.000,00). Ao chegar no plantão, começou a passar mal e foi levado até a Santa Casa. Após, foi levado até o Batalhão da Polícia Militar. Disse que não sabia que a residência era ponto de drogas. Por fim, afirmou que pagava R\$600,00 (seiscentos reais) de aluguel e que trabalhava como mecânico para uma pessoa chamada Marcos. Reiterou que não trabalhava para OSVALDINO e não o conhecia

(v. mídia).

O réu Osvaldino, quando interrogado na fase policial, declarou ter sido proprietário da casa situada no local dos fatos, vendendo-a para Poliana Isabel da Silva no ano de 2011. Disse não conhecer ALEXANDRE e não ter conhecimento das drogas. Ressaltou que mora em Ribeirão Preto, mas vem a Sertãozinho diariamente ver seus filhos. Sabe que Poliana também reside em Ribeirão Preto. Apresentou compromisso de compra e venda a fls. 108/110 (fls. 106/107).

Em juízo, o réu Osvaldino negou a acusação. Disse que não conhece ALEXANDRE e que tomou conhecimento dele apenas na presente data. Afirmou que, à época, tinha uma empresa de construção civil em Sertãozinho. Ademais, declarou que já cumpriu pena por roubo. Esclareceu que tomou conhecimento dos fatos porque foi intimado para prestar depoimento sobre o ocorrido, tendo dito que não tinha nenhuma ligação com os fatos. Disse que comprou a residência local dos fatos quando ela era loteamento, mas que a vendeu posteriormente, no ano de 2011, ainda como terreno. Ademais, disse que não conhecia os policiais militares que prenderam ALEXANDRE. Disse que já chegou a registrar Boletins de Ocorrência contra Policiais Militares por perseguição. Declarou que vinha a Sertãozinho para ver os filhos e a família e também para pegar alguns serviços, como de pintura e construção. Por fim, disse que, na data dos fatos, não estava em Sertãozinho e que não faz parte de nenhuma facção criminosa (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que os acusados Alexandre e Osvaldino eram realmente os proprietários das drogas apreendidas, as quais se destinariam à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais militares, eles receberam notícia anônima dando conta de que no local dos fatos praticavam o tráfico de drogas. Ao se deslocarem para lá, depararam-se com ALEXANDRE, momento em que também encontraram certa quantidade de maconha e cocaína perto da janela, as quais foram confirmadas no laudo pericial de fls. 58. Posteriormente, o réu informou aos agentes de segurança que havia dispensado drogas pelo cano de água, tendo os policiais quebrado o local mencionado e encontrado a outra parte dos entorpecentes apreendidos. Em sequência, ALEXANDRE confessou que estava morando ali porque trabalhava para OSVALDINO, o qual lhe pagava R\$600,00 (seiscentos reais) por dia de serviço. Ademais, ainda foram encontrados no local uma televisão, ligada a cabos de monitoramento, através de câmeras de segurança, bem como R\$1.098 (mil e noventa e oito reais) em espécie e em notas trocadas, descritos no auto de exibição/apreensão de fls. 27/28.

Também é certo que os réus ALEXANDRE e OSVALDINO não comprovaram de forma satisfatória o exercício de qualquer atividade remunerada lícita, motivo pelo qual não foi satisfatoriamente comprovada a origem do dinheiro encontrado em poder do réu ALEXANDRE, podendo-se concluir que realmente viviam desta prática ilícita. Destaco ainda o fato de ser o réu OSVALDINO conhecido nos meios policiais pela prática de crimes, inclusive o tráfico de drogas, por já ter sido abordado em outras oportunidades em relação a tal delito. Ademais, há informes de que seria integrante do PCC, exercendo o papel de “patrão” do tráfico de drogas pelo bairro Jardim Helena, em Sertãozinho (v. fls. 59/61).

Além disso, restou comprovado que na data de 04 de agosto de 2014, isto é, 3 dias após a prática do delito, a Central de Atendimento ao Cidadão de Sertãozinho recebeu solicitação de alteração de titularidade do imóvel local dos fatos, pertencente ao réu OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS, para Poliana Isabel da Silva. Tal fato corrobora o entendimento de que o réu terminava a persecução criminal em relação aos fatos e procurou rapidamente evitar a responsabilidade penal e eventual sequestro do bem utilizado exclusivamente na prática delitiva (cf. fls. 433/441). Não bastasse tal fato, também restou comprovada fraude no contrato de compra e venda do imóvel local dos fatos, cuja cópia foi apresentada nos autos pelo próprio réu OSVALDINO (fls. 108/110). Ainda, denota-se que no reconhecimento de firma da cópia do referido contrato, a data do ato ficou prejudicada (apagada), de forma

aparentemente proposital, de modo que não há como confirmar o ano em que foi realizada. Neste sentido, em que pese tenha o réu afirmado em juízo que tal documento tenha sido elaborado no ano de 2011, há referência expressa ao valor venal do imóvel no ano de 2014 (folha 108), fato que o desabona e efetivamente comprova a propriedade do imóvel em seu nome.

O relato posto pelo acusado Alexandre, em sede de autodefesa judicial, sobre a forma como a residência foi invadida não encontra ressonância em nenhuma fonte de prova trazida à apreciação judicial. Narrou o acusado que estava dormindo, quando sua casa foi invadida por policiais militares, os quais entraram no domicílio com destruição da laje, pelo telhado. A forma, em tese, como os agentes de segurança entraram na residência deixaria muitas evidências, sendo simples ao acusado colacionar fotos ou valer-se de testemunhas para corroborar sua versão, mormente pelo fato de estar sempre assistido por advogada constituída, amparado tecnicamente para produção de provas em favor de sua defesa, providências não tomadas ao longo de toda instrução inquisitiva e processual.

Observe-se que a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova documental e pericial já citadas, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que tivessem a intenção de prejudicar os acusados ou obter qualquer vantagem indevida.

Assim, considerando a significativa quantidade de drogas encontradas no local dos fatos (147,24 g de maconha e 156,57 g de cocaína), a variedade de espécies, bem como que todas estavam embaladas e prontas para consumo, presume-se que realmente eram destinadas à comercialização.

Deste modo, reputo que os dois realmente atuavam em conjunto nesta atividade ilícita, conforme acusação feita na inicial.

Em relação ao delito previsto no art. 35 da lei de drogas, reputo que não ficou devidamente caracterizado, posto que inexistem notícias de que os réus efetivamente estavam associados, de forma estável e permanente, para o comércio ilícito de drogas.

No caso em tela, a ligação entre OSVALDINO e ALEXANDRE restou evidenciada após a confissão informal deste, contudo, não há qualquer prova de que também tivessem atuado juntos em outra data. Segundo os policiais, na denúncia anônima recebida por eles, não constava o nome de OSVALDINO, mas tão somente dizia que indivíduos praticavam o tráfico de entorpecentes no local dos fatos.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, ademais, é imprescindível o dolo de se associar e que haja um mínimo de estabilidade e organização nesta associação, não bastando a mera reunião de duas ou mais pessoas para a prática conjunta do tráfico em determinada data específica.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi parcialmente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação dos réus como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, observo que o réu Osvaldino apresenta diversos maus antecedentes (v. fls. 754/760 e 761/778 - autos 333/1999 e 0009473-32.2007.8.26.0368), motivo pelo qual majoro sua pena em 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em relação ao réu Alexandre, fixo a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da multirreincidência do réu (v. fls. 778/779 - autos 32/2004, 0002817-6.2004 e 0008062-48.2004), sua pena é majorada em 1/5, alcançando 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tal benesse deve ser concedida apenas aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização criminosa.

Porem, o Osvaldino ostenta diversos maus antecedentes, tratando, outrossim, de multirreincidente, impossibilitando a consideração do redutor. Além disso, foi apreendida significativa quantidade da droga cocaína na data dos fatos, que além de indicativa de profissionalização na conduta, representa um perigo maior à saúde pública, por atingir inúmeros usuários, de forma que sua conduta evidentemente implica alto risco à sociedade. A cocaína ainda apresenta elevado grau de prejuízo à saúde, altamente viciante, restando configurado, ainda, que o réu Alexandre não possui ocupação lícita, surpreendido em local conhecido pelo tráfico de drogas, constatando-se sua dedicação à atividades criminosas, sendo inclusive sentenciado por crime da mesma espécie (vide autos nº 0006771-32.2012, folhas 752/753), alcançado pela prescrição.

E segundo os policiais, o local dos fatos era muito conhecido como ponto de venda de drogas, e os réus como traficantes. Por todos referidos motivos, os réus não podem ser considerados mero traficantes eventuais ou se sustentar que não se dedicam a atividades criminosas.

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e,

ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta aos réus, nos termos do artigo 33, § 1º, “a” c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, conforme já ressaltado, os réus foram flagrados mantendo em depósito

relevante quantidade de entorpecente, em local muito conhecido na cidade como ponto de tráfico de drogas. Além disso, os réus deixaram de comprovar o exercício de qualquer atividade remunerada lícita, demonstrando que viviam da prática do tráfico, não podendo ser brandamente apenados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 1/5, alcançando 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor mínimo; o réu ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como ABSOLVÊ-LOS da prática do delito previsto no art. 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Faculto recurso em liberdade.

Em face da condenação, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 20 de julho de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA